

不能证明是犯罪所得或通过犯罪 所得所购置的财物如何处置

——何某等开设赌场案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区柳州市中级人民法院(2023)桂02刑终161号刑事判决书

2. 案由: 开设赌场罪

【基本案情】

2021年9月,同案犯曾某与他人(另案处理)预谋共同架设一款手机赌博APP,并约定由他人组织团队进行软件研发,曾某负责进行推广。2021年年底,手机赌博APP(先后命名为“A”“B”“C”)研发成功上线运行。2022年年初,同案犯王某受曾某的指派,到广西推广“B”赌博APP,招募了被告人何某等多名代理并接受投注,其中何某为广西“盟主”,之后,何某又发展了王某等多名下级代理并接受投注,参与利润分成。经统计,2022年3月18日至5月22日,何某及其下级代理在该赌博APP的赌资总流水为8850011元。

2022年5月22日23时许,被告人何某被抓获归案。另查明:(1)公安机关从何某处扣押了苹果手机1部、华为手机1部、平板电脑1台、银行卡6张;(2)何某名下农业银行卡中29277.05元被公安机关依法冻结、何某名下工商银行卡中3163.23元被公安机关依法冻结;(3)何某利用其收取的赌资于2022年3月23日购买的某小区×号楼×x房(登记在其妹何某1名下)被公安机关依法查封;(4)覃某将其代被告人何某收取的赌资6885元退缴到公安机关账户。

【案件焦点】

登记在被告人亲属名下的房产能否认定为赌资所购，是否应予没收。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民法院经审理认为：被告人曾某以营利为目的组织赌博活动，利用互联网、移动终端传输赌博数据，建立赌博网站并接受投注，参与赌博网站利润分成，情节严重；被告人王某、何某、王某以营利为目的，利用互联网、移动终端传输赌博数据，为赌博网站担任代理并接受投注，参与赌博网站利润分成，情节严重；被告人严某明知曾某开设赌场仍加入，并按照曾某的指派从事相关工作，五名被告人的行为均触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，构成开设赌场罪。在共同犯罪过程中，被告人曾某、王某、何某、王某起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；但相对于曾某而言，王某、何某、王某是作用较小的主犯，量刑时酌情从轻处罚；被告人严某起辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。据此，以开设赌场罪，分别判处五名被告人六年至二年六个月不等刑期，并处罚金，对查封、扣押的被告人的违法所得及相关财物依法没收或冲抵财产刑。

宣判后，被告人何某提出上诉，其中一个上诉理由是某小区×号楼××房是其妹妹何某1出资购买，请求返还。

广西壮族自治区柳州市中级人民法院经审理认为：原判认定原审被告人何某、王某、曾某、王某、严某犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实充分，定性准确。原判根据各原审被告人的犯罪事实、性质和对社会的危害程度，综合考量各原审被告人在共同犯罪中的地位作用，以及认罪悔罪态度等情节，决定各被告人量刑适当。原判认定某小区×号楼×x房系何某违法所得予以没收不当，予以纠正。据此，判决如下：

一、维持广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民法院(2022)桂0203刑初521号刑事判决第一项、第二项、第三项、第四项、第五项，以及第六项(附表二)中的序号1至8、10至14中的涉案财物处置；

二、撤销广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民法院(2022)桂0203刑初521号刑事判决第六项(附表二)中的序号9,即某小区×号楼xx房,予以没收并上缴国库;

三、查封在案的某小区×号楼xx房,发还产权人。

【法官后语】

一、涉案财物归属的审查

根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二百七十九条的规定,法院在受理涉财产处置案件时,应充分审核公诉机关移交的案卷材料中是否附有《提请人民法院依法处置涉案财物清单》,在庭审中应当对查封、扣押、冻结财物及其孳息的权属、来源等情况,是否属于违法所得或者依法应当追缴的其他涉案财物进行调查,由公诉人说明情况、出示证据、提出处理建议,并听取被告人、辩护人等诉讼参与人的意见。案外人对查封、扣押、冻结的财物及其孳息提出权属异议的,应当听取案外人的意见。由此可见,法院对于查扣在案的涉案财产权属应进行主动审查,并按照法律规定,对属于被告人名下和非被告人名下的财产进行甄别后进行处置,如果涉及案外人的,则应当听取案外人的意见。

二、在案证据无法充分证实查扣在案的非被告人本人名下的涉案房产系用赃款购买的情况下不应没收

一审法院根据房屋销售经理覃某的证言、支付宝和微信的收款记录等证据,认定何某向覃某表达购房意愿后,通过覃某的支付宝和微信的收款二维码在两个月内陆续有数额不等的钱款转入覃某的支付宝和微信,共收取72999元,认定该款属于赌资,虽然房子最终登记在何某1的名下,但仍据此判决予以没收。但二审过程中,被告人何某提出某小区×号楼××房是其妹妹何某1出资购买,辩护人提供了不动产查询材料、买卖协议书、何某1名下银行账户于该处房产交易当日转账43万元给原房主毛某的记录、何某1及其丈夫潘某、原房主毛某的证言、何某1及其丈夫潘某养殖场的营业执照等证据,二审法院认为,在案证据不足以证明何某1上述购房款系从何某处获取,或者何某用涉案赌资购买,

因此采纳了何某的意见，作出相关房屋返还产权人的判决。

本案中，虽然何某有和覃某表达购买房子的意愿，亦转账部分款项给覃某，但不能据此认定该房子就属于何某用赌资购买以及属于其名下资产。首先，金钱是种类物，何某本人未曾供述给覃某的款项系赌资。其次，该房子的产权登记人是何某1，何某1也支付了43万元，远远超出何某支付的费用，且目前在案证据无法证实何某1支付的43万元系何某给其，更无法证实43万元系赌资，不动产权证书上面也没有何某名字。最后，亦没有其他任何证据证实该房产系何某和何某1共同共有。

编写人：广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民法院 谢剑峰 尹嘉嘉